

1500086-62.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/08/2022

... Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente. Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500086-62.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500086-62.2018.8.26.0616 2018/002031

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2048317/2018 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES, 1472666 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES,

1727/18/311 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2048317 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES,

1727/18/311 - 03º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO RODRIGUES GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

MÁRCIO RODRIGUES GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo apurado, no dia 06 de setembro de 2018, por voltadas 14h30, na Rua Santos, Botujuru, nas proximidades de sede de entidade beneficente e social (Igreja Plenitude da Fé), nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, trazia consigo e guardava, para fornecimento a terceiros, certa quantidade da droga Cannabis sativa

L, conhecida popularmente como maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R\$40,00.

Houve prisão em flagrante, convertida em prisão preventiva conforme r. decisão proferida no termo de audiência de custódia fls. 42/44.

O acusado foi notificado (fls. 104) e apresentou defesa preliminar (fls. 111/112). A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2019 (fls. 127).

Citado (fls. 149), apresentou resposta à acusação (fls. 161 e 187/190).

Foi concedida liberdade provisória em 16/09/2019, mediante compromisso de não se ausentar da comarca por mais de 8 dias, nem mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo (fls. 196).

Produziu-se prova oral, com a oitiva de duas testemunhas, sendo decretada a revelia do acusado (fls. 260/261).

Encerrada a instrução probatória, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público pleiteou a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e, subsidiariamente, pugnou pela aplicação do redutor (fls. 260/261).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede o pedido contido na denúncia.

A materialidade do delito está configurada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 08/10), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), laudo de constatação (fls. 19/26), guia de depósito judicial (fls. 80), laudo de exame químico-toxicológico, o qual resultou positivo para tetrahydrocannabinol (TCH) (fls. 114/116), laudo da sacola plástica e rolo de filme PVC apreendidos (fls. 130/131), laudo do local (fls. 144/146), bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria criminosa do réu evidenciou-se.

Em Juízo, a testemunha Adalberto Julião dos Santos, Policial Militar, narrou que foram até o local em razão de denúncias feitas no disque-denúncia e, lá chegando, abordaram o acusado. Com ele, foram localizadas 6 porções de maconha, além de R\$40,00. Informalmente, ele admitiu o tráfico. Perguntaram se tinha mais e ele, em tom de deboche, disse “tem, pode procurar”. Solicitaram apoio do canil, porque era uma área grande, com mato e bastante bambu. Foi encontrada grande quantidade de maconha próxima ao bambuzal onde ele estava, o que totalizou 96 porções, pesando mais de 700 gramas. Não se recorda se o réu admitiu a propriedade das drogas que foram encontradas depois, mas ele confirmou que existia mais no local. Não conhecia o réu anteriormente. Não se recorda se na denúncia anônima havia descrição do acusado, mas o local já era conhecido como ponto de tráfico. Não se recorda se chegou a visualizar algum ato de mercancia. Não consegue precisar a distância entre o réu e a droga localizada. É uma área de mato, um pouco alto e eles conseguem visualizar a chegada da viatura. Alguns fogem e outros ficam no local para ser abordado. Nesse dia eles não conseguiram visualizar a chegada da polícia e, por isso, conseguiram aborda-los. O depoente abordou só ele.

No mesmo sentido, a testemunha Washington Machado, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento e foram averiguar um disque-denúncia na Rua Santos. Lá, avistaram um indivíduo, que tentou empreender fuga por poucos metros e foi abordado. Com ele, foram localizadas 6 porções de maconha e cerca de R\$40,00. Ele admitiu a traficância. Perguntado se havia mais porções, ele respondeu “tem, procure”. Por ser uma área extensa, mata densa, bambuzal, folhagens, acionaram a equipe do canil, que encontrou uma porção maior de droga, próximo ao bambuzal em que ele estava. Foram localizadas cerca de 90 porções de maconha, com as mesmas características da droga encontrada em seu poder, totalizando cerca de 760 gramas. O local já era conhecido como ponto de tráfico de drogas, por vários disque-denúncia. Recebiam vários disque-denúncias, com várias características, sempre nesse local. No momento da abordagem só tinha o acusado, sentado à beira de um barranco, exatamente como descrito no disque-denúncia. Não se recorda se o acusado admitiu a propriedade das demais drogas apreendidas. Não conhecia o réu anteriormente.

O acusado Marcio Rodrigues Gomes, ouvido em sede policial, disse que “é usuário de

crack há mais de vinte anos, e que na data de hoje, em razão de seu vício foi até o local dos fatos para adquirir crack, e adquiriu duas pedras ao preço de R\$ 10,00, não podendo indicar qualificação ou apelido de quem lhe forneceu a droga, sendo que agora o interrogado informa que foi o "Neguinho". O interrogado esclarece que foi até o final do terreno, onde existe uma "casinha" própria para se utilizar entorpecente, já que é desabitada. Perguntado respondeu que nesse exato momento apareceu a polícia militar e fez uma busca naquele local, nada sendo encontrado, porém momentos depois, um dos policiais militares alegou ter achado um saco plástico com maconha. Na sequência, um ou dois cães farejadores encontraram distante daquela casinha, outra quantidade de maconha. O interrogado quer consignar que tanto o primeiro saquinho com maconha como a segunda quantidade encontrada posteriormente, não lhe pertencem, e não sabia que lá estavam escondidas. Perguntado sobre a quantia de R\$ 40,00, o interrogado informa nada saber, pois como dito, a quantia estava dentro daquele saquinho de maconha, e assim acredita que dos R\$ 40,00, o valor de R\$ 20,00 seria o que foi dado quando da aquisição do crack" (fls. 05/06).

Com efeito, a autoria criminosa está suficientemente demonstrada.

Importante ressaltar que as palavras dos policiais militares merecem total credibilidade e nada há nos autos que desmereça seus relatos, até mesmo porque não há indícios de que os agentes já conhecessem o acusado anteriormente e porventura quisessem prejudicá-lo.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípua"(TJRJ -AC. -Rel. Synésio de Aquino -RDTJRJ 7/287).

Ressalte-se que eventuais imprecisões nos depoimentos prestados pelos policiais militares, como apontado pela defesa, não tem o condão de enfraquecer a prova acusatória, pois é natural que, em razão do tempo decorrido e das inúmeras ocorrências semelhantes, existam pequenas divergências em seus depoimentos, o que não retira a validade e credibilidade destes.

No mais, o fato de ser usuário, por si só, não afasta a traficância, pois é justamente pela venda que o usuário satisfaz o consumo. Desta forma, o elemento subjetivo do tipo penal restou plenamente configurado, tendo em vista a ciência do réu em relação às drogas.

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº11.343/06, não se exige qualquer ato de tráfico, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo e tenha em depósito a substância entorpecente.

Já decidiu o STF que "a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

No mesmo sentido: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO.

NULIDADE. MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO DE JUDICIAL. SÚMULA 282 DO STF. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. Assim, como assentado no acórdão, "para a configuração do delito de tráfico de drogas não é preciso a comprovação da mercancia, bastando que seja praticada uma das condutas contidas no tipo penal". Assim, diante do contexto dos autos, as instâncias ordinárias, soberanas no exame das provas, concluíram que "a confissão do adolescente V. não teria o condão de afastar a responsabilização criminal da acusada devidamente demonstrada nos autos originários". Incidência da Súmula 7 do STJ. (...) (STJ. AgRg no AREsp n. 1.989.750/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022, g.n.)

Nesse lastro, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, pela responsabilidade do acusado quanto aos fatos descritos na inicial.

Por fim, a majorante prevista no inciso III, do artigo 40, da lei de Drogas

(proximidade de igreja), foi devidamente demonstrada, conforme laudo do local às fls.144/146.

Neste sentido: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. CRIME REALIZADO PRÓXIMO A IGREJA. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.(...) 2. O objetivo da lei, ao prever a causa de aumento de pena do inc. III do art. 40, é proteger espaços que promovam a aglomeração de pessoas, circunstância que facilita a ação criminosa (AgRg no AREsp 1.028.605/SP, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, DJe 10/8/2018). Assim, tendo o delito sido cometido nas imediações de igrejas, impõe-se a manutenção da incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006.

Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.965.596/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021, g.n.).

Passo ao cálculo da pena.

Na primeira fase, observo que, devido à quantidade de entorpecente apreendido, não lhe favorecem os critérios do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei 11.343/06. Assim sendo, a pena deve ser aumentada em 1/6, chegando ao patamar de 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e/ou atenuantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, incidirá o aumento de 1/6, perfazendo, assim, 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, e 680 dias-multa, no mínimo legal.

O acusado não faz jus ao benefício previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06. É cediço que o tráfico, enquanto comércio ilícito altamente lucrativo, é atividade exercida segundo o domínio territorial. Através do uso ilegítimo da força, as organizações criminosas instituem formas de domínio sobre os pontos conhecidos de venda de drogas, falando-se, inclusive, em "propriedade", "arrendamento" e "locação" destes espaços.

Desta forma, o exercício da traficância, nestes locais, indica inserção do agente nesta estrutura e a sua dedicação às atividades criminosas, impossibilitando a incidência em seu favor da figura privilegiada. Além disso, a quantidade de droga e forma de acondicionamento é indicativa dessa dedicação às atividades criminosas.

Neste sentido:

(...) na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada (...) nas demais circunstâncias da apreensão e da prisão em flagrante do paciente, (...) a apreensão (uma parte do entorpecente encontrada na posse do réu em local conhecido pela venda de drogas (...) elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. AgRg no HC 568062/MS, Rel. Min. Félix Fischer, julgado em 26/05/2020, DJe 03/06/2020.

Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas, quais sejam, 50 (cinquenta) eppendorfs de cocaína e 49 (quarenta e nove) invólucros de maconha, em local conhecido como "ponto" não poderia atuar se já não fosse dedicada ao crime, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que a paciente se dedicava às atividades criminosas, em consonância com o entendimento desta Corte. HC 541065/SP, Rel. Min. Leopoldo de Arruda raposo, julgado em 20/02/2020, DJe 02/03/2020.

A desconstituição do entendimento do Tribunal de origem por via do presente mandamus é inviável, pois obstado pela impossibilidade do Superior Tribunal de Justiça reapreciar o contexto fático-probatório, notadamente na hipótese, em que "houve fundamentação concreta por parte das instâncias ordinárias para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava a atividades criminosas (traficância), em razão das circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (local conhecido como base do tráfico na região), bem como pelas testemunhas policiais". HC 474680/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em

21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Encontrando-se devidamente fundamentado o reconhecimento da dedicação à atividade criminosa pelo Tribunal de origem diante da grande quantidade de droga e pela forma de armazenamento da droga, a desconstituição das premissas fáticas deduzidas no acórdão encontra óbice na Súmula 7/STJ. AgRg no AgRg no AREsp 1293036/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018.

Consoante decidido pelas instâncias ordinárias, além da quantidade e da variedade de droga apreendida na posse dos agravantes - 75 (setenta e cinco) pedras de crack, 48 (quarenta e oito) porções de cocaína e 29 (vinte e nove) de maconha -, a forma de acondicionamento das substâncias entorpecentes, embaladas e organizadas para a comercialização ilegal e entrega a consumo de terceiros, demonstram a dedicação para a prática da atividade ilícita. AgRg no HC 547549/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/05/2020, DJe 29/05/2020.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado considerando a gravidade, em concreto, do delito praticado e a quantidade de porções de droga maconha apreendida. Não se compatibiliza, portando, com regime mais brando.

Entendo insuficiente a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Neste sentido:

"O óbice, previsto no art. 44 da Lei n. 11.343/2006, à suspensão condicional da pena imposta ante tráfico de drogas mostra-se afinado com a Lei n. 8.072/90 e com o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal" (STF, HC 101.919/MG, 1ª Turma, rel. Min. Marco Aurélio). "Não se mostra socialmente recomendável a conversão da pena privativa de liberdade em sanções restritivas de direitos, tendo em vista as peculiaridades do caso, que justificaram, aliás, a aplicação do redutor em patamar intermediário, em razão da variedade e quantidade da droga apreendida" (STJ, HC 206015/RJ).

Logo, ante todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu MÁRCIO RODRIGUES GOMES, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo legal, à mingua de maiores informações acerca da capacidade econômica do réu.

Poderá o réu apelar em liberdade.

Em função do tráfico de drogas se tratar de crime de crime vago, com sujeito passivo indeterminado, não se cogita da fixação para a reparação civil do ofendido (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal).

Ainda, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Declaro a perda do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas, nos termos da Lei nº 11.343/06 (fls. 80).

Autorizo a incineração das drogas apreendidas nos moldes do artigo 524 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça, se o caso.

Quanto aos demais objetos apreendidos (sacola plástica e rolo de filme PVC), em razão da inexpressividade econômica, autorizo a destruição (fls. 11/12). Oficie-se. Após o trânsito em julgado:

- (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;
- (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;
- (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal;
- (iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);
- (v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso

não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo ao réu.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA